

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출][1][2009-1]해고의 예고와 해고의 서면 통지에 대한 의의, 내용, 예외, 법적 효과

《【문제1】 근로기준법상 해고절차의 제한 가운데 해고의 예고 및 해고의 서면통지에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 해고의 예고와 해고의 서면 통지에 대한 의의, 내용, 예외, 법적 효과

**I. 문제 제기**

- 근로기준법은 정당한 이유 없는 해고를 금지하는 실체적 제한(근로기준법 제23조) 외에도 해고의 시기, 방법, 절차 등에 관한 절차적 제한을 규정하여 근로자를 보호한다. 이러한 절차적 제한 중 핵심은 사용자가 근로자를 해고할 때 최소한의 예고 기간을 부여하여 근로자의 생계를 보호하고(근로기준법 제26조), 해고의 사유와 시기를 서면으로 명확히 통지하여 근로자의 방어권과 다툼 기회를 보장하는(근로기준법 제27조) 제도이다. 이하에서는 근로기준법상 해고 절차의 주요 제한인 해고의 예고 및 해고의 서면 통지 제도에 관하여 그 의의, 내용, 예외, 법적 효과를 중심으로 논한다.

**II. 해고의 예고 [근로기준법 제26조]**

**1. 해고 예고 제도의 의의 및 취지**

- 근로기준법 제26조는 사용자가 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하거나, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급하여야 한다고 규정한다. 그 취지는 근로자가 갑작스러운 해고로 인해 받게 될 경제적 어려움에서 벗어나 새로운 직장을 구할 수 있는 시간적·경제적 여유를 부여함으로써 근로자의 생활 안정을 도모하는 데 있다.

**2. 해고 예고의 방법 및 내용**

- 해고 예고 자체는 반드시 서면으로 할 것을 요구하는 강행규정은 아니다. 구두, 서면 등 그 방법을 불문하며, 해고일이 명확하게 명시되어 통보되었다면 유효하다. 다만, 해고의 서면 통지(근로기준법 제27조) 규정의 취지와 실무적 관행을 고려할 때, 예고 역시 서면으로 하는 것이 바람직하다. 예고의 내용에는 해고의 의사와 실제 해고가 이루어지는 날짜(30일 이후)가 명확하게 포함되어야 한다.

**3. 해고 예고 의무의 예외**

- 근로기준법 제26조 단서 및 근로기준법 시행규칙 제4조는 해고 예고 의무가 적용되지 않는 예외적인 경우를 규정하고 있다. 이러한 예외 사유가 인정되는 경우 사용자는 30일분의 통상임금을 지급하지 않고 즉시 해고할 수 있다.

**(1) 근로자의 계속 근로 기간이 짧은 경우**

- 계속 근로 기간이 3개월 미만인 근로자에게는 해고 예고 의무가 적용되지 않는다. 이는 고용 초기 단계에서는 고용 관계의 안정성이 낮고, 해고 예고 통지를 통한 보호 필요성이 상대적으로 낮다는 점을 고려한 것이다.

**(2) 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업이 불가능한 경우**

- 천재지변 등 사업주에게 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 사업의 계속이 불가능하게 된 경우를 말한다. 다만, 사업 계속이 불가능한지 여부는 사용자의 노력에도 불구하고 객관적으로 사업장 전체의 존립이 위태로울 정도에 이르렀는지 여부를 엄격히 판단해야 한다.

**(3) 근로자가 고의로 사업상·재산상 손해를 끼친 경우**

- 근로자의 중대한 귀책사유가 있는 경우 해고 예고 의무가 면제된다. 구체적인 사유는 근로기준법 시행규칙 별표에 열거되어 있으며, 해고 예고의 면제는 노동위원회의 승인을 얻어야 한다.

**① 시행규칙상의 사유**

- 근로기준법 시행규칙 제4조 별표1에는 불량품 수령으로 생산 차질 야기, 영업용 차량 대리운전, 사업 기밀 유출, 허위 사실 날조, 공금 착복·횡령·배임, 제품·원재료 절도 및 불법 반출, 근로자 근무 실적 조작, 사업장 기물 파손, 기타 사업 지장 및 재산상 손해 초래 등 9가지 사유가 열거되어 있다.

**② 판단 기준**

- 법원 및 행정해석은 근로자의 행위가 고의 또는 이에 준할 정도의 중대한 과실로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼쳤는지 여부를 구체적이고 엄격하게 심사해야 한다고 본다.

**4. 해고 예고 수당**

**(1) 수당의 성격**

- 해고 예고 수당은 해고 예고 기간(30일)을 두지 않고 즉시 해고하는 경우, 근로자의 생활 보장과 전직 기회 제공을 위해 지급되는 법정 손해배상금 내지 전직 활동 지원금의 성격을 가진다. 이는 근로의 대가인 임금인 아니므로, 임금채권보장법상의 대지급금 지급 대상에 포함되지 않는다.

**(2) 위반의 효과**

- 사용자가 해고 예고를 하지 않고 해고예고수당도 지급하지 않은 경우에도, 해고예고수당을 지급할 때까지 해고의 효력이 발생하지 않는 것은 아니다. 즉, 해고 자체의 유효성은 근로기준법 제26조의 위반 여부와 관계없이 실체적인 정당성(근로기준법 제23조)에 따라 결정된다. 다만, 해고 예고 의무를 위반하고 수당을 지급하지 않은 사용자는 근로기준법 제110조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는 벌칙의 대상이 된다.

**III. 해고의 서면 통지 [근로기준법 제27조]**

**1. 해고 서면 통지 제도의 의의 및 취지**

- 근로기준법 제27조는 해고는 서면으로 그 사유와 시기를 통지하여야 효력이 있다고 규정하는 강행규정이자, 해고의 유효 요건 중 하나인 절차적 요건이다.

**(1) 해고의 존재 명확화**

- 해고 통지의 방법과 시기를 명확히 함으로써 해고의 존부를 둘러싼 분쟁을 예방하고, 사용자의 자의적인 해고를 억제한다.

**(2) 해고의 사유 명확화**

- 서면 통지를 통해 사용자가 근로자에게 해고 사유를 객관적으로 명시하도록 강제하여, 향후 해고 정당성 여부에 대한 다툼의 범위를 한정하고 심리를 용이하게 한다.

**(3) 근로자의 방어권 보장**

- 근로자에게 해고 사유를 정확하게 알려줌으로써 근로자가 구제 절차를 진행할지에 대한 판단과, 구제 절차 시 방어 준비를 효율적으로 할 수 있도록 방어권을 보장하는 데 가장 큰 취지가 있다.

**2. 서면 통지의 방법 및 내용**

## (1) 통지의 방법

### ① 서면 통지의 강제

- 근로기준법 제27조는 해고 통지는 서면으로 하여야 한다고 명시하고 있으므로, 구두나 문자 메시지, 이메일 등 비서면 방식의 통지는 원칙적으로 무효이다. 서면은 종이 문서를 의미한다.

### ② 전자 문서의 허용 가능성

- 대법원 판례는 근로자가 해고 통지의 내용을 확인할 수 있고, 그 서면을 보존할 수 있는 등 종이 문서에 의한 통지와 동등하게 근로자의 방어권 보장에 지장이 없는 경우라면, 전자 문서(전자우편, 문자 메시지)에 의한 통지도 근로기준법 제27조의 서면 통지로 볼 수 있다는 가능성을 인정하고 있다. 다만, 근로자에게 해고 통지가 정확하게 전달 및 수신되었는지와 근로자가 이를 출력 또는 보존할 수 있는지에 대한 엄격한 확인이 필요하다.

## (2) 통지의 내용

### ① 해고 사유의 구체성

- 통지된 서면에는 해고의 정당성을 뒷받침할 수 있는 구체적인 사실과 해고의 징계 사유가 명확하게 기재되어야 한다. 단순히 취업규칙의 해당 조항이나 징계 사유를 나열하는 것에 그치지 않고, 근로자가 어떠한 행위를 하였기 때문에 해고되는지를 충분히 알 수 있도록 구체적인 비위 사실을 적시해야 한다.

### ② 해고 시기의 명확성

- 해고의 효력이 발생하는 날짜를 명확하게 기재해야 한다. 해고 시기가 불분명하거나 통보일로부터 30일 이내에 해고일이 지정되지 않은 경우에는 해고의 효력이 불분명해져 법적 분쟁의 소지가 발생한다.

## 3. 서면 통지 의무 위반의 효과 (판례 법리)

### (1) 절차적 무효

- 근로기준법 제27조 제2항은 해고는 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하므로, 서면 통지 의무를 위반한 해고는 절차적 정당성을 결여하여 해고 전체가 무효가 된다. 해고 사유의 실체적 정당성이 인정되더라도, 서면 통지 절차를 거치지 않은 이상 해고는 그 효력을 가질 수 없다.

### (2) 서면 통지 후의 효력

- 해고 통지가 서면으로 이루어지지 않아 무효인 경우, 사용자가 추후 해고의 효력 발생 시점을 명시하여 다시 서면으로 통지하면, 그때부터 새로운 해고 통지로서 효력을 발생할 수 있다. 이때 새로운 서면 통지는 징계 해고의 경우 징계 사유의 시효 등을 준수해야 한다.

## IV. 해고 예고와 해고 서면 통지 규정의 관계

### 1. 제도의 목적 및 성격

#### (1) 해고 예고 [제26조]

- 근로자의 경제적·시간적 여유를 부여하여 이직을 준비하고 생활 안정을 도모하는 경제적 보호 제도의 성격이 강하다.

#### (2) 해고 서면 통지 [제27조]

- 해고의 존재 및 사유를 명확히 하여 근로자의 방어권을 보장하고 분쟁을 예방하는 절차적 정당성 확보 제도의 성격이 강하다.

### 2. 적용의 관계

#### (1) 별개의 절차 요건

- 근로기준법 제26조와 제27조는 해고의 효력을 위한 별개의 절차적 요건이다. 즉, 해고 예고를 충실히 하였다고 하더라도 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하지 않았다면 그 해고는 무효이다. 반대로 서면 통지를 완벽하게 하였더라도 30일의 예고 기간을 두지 않았거나 예고 수당을 지급하지 않았다면 그 해고의 효력이 부정되는 것은 아니나 사용자는 별칙의 대상이 된다.

#### (2) 해고 예고 수당 지급과 서면 통지

- 사용자가 해고 예고 기간(30일)을 준수하지 않고 즉시 해고하면서 해고 예고 수당을 지급하였다 하더라도, 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하는 의무(근로기준법 제27조)는 면제되지 않는다. 해고 예고 수당의 지급은 해고 예고 의무 위반에 대한 대체적 이행일 뿐, 서면 통지 의무의 면제 사유가 될 수 없다.

#### (3) 검토

- 두 규정은 목적과 법적 효과가 다르므로, 사용자는 해고 시 해고 예고와 해고 서면 통지라는 두 가지 절차적 의무를 모두 충족해야 한다.

## V. 결론

- 근로기준법상 해고 절차의 제한인 해고 예고(근로기준법 제26조)와 해고 서면 통지(근로기준법 제27조)는 근로자의 생활 안정을 도모하고 방어권을 보장하는 중요한 절차적 장치이다. 특히, 해고의 서면 통지는 해고의 효력 요건으로서 그 위반 시 해고가 무효가 되는 중대한 절차적 하자를 구성하므로, 사용자는 해고 시 그 사유와 시기를 명확하게 기재한 서면을 근로자에게 교부해야 할 의무를 엄격히 준수해야 한다. 이러한 절차적 제한의 준수는 해고의 정당성을 확보하는 데 필수적인 전제 조건이 된다.